

1500051-83.2020.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500051-83.2020.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500051-83.2020.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2051018/2020 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 10181036 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 495/20/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 497/20/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 498/20/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 2051018 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 495/20/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 497/20/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 498/20/212 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 2051018 - DEL.POL.RUBINEIA, 495/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA, 497/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA, 498/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA, 2051018 - DEL.POL.RUBINEIA, 495/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA, 497/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA, 498/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA, 2051018 - DEL.POL.RUBINEIA, 495/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA, 497/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA, 498/20/212 - DEL.POL.RUBINEIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIK DA SILVA SANTANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

CAIK DA SILVA SANTANA foi denunciado como incurso no art. 306, §1º, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 171 c.c arts. 14, inc. 11, e 29, ambos na forma do art. 69, estes últimos do Código Penal. Por sua vez, CÍCERO PINHEIRO MALHEIROS foi denunciado como incurso no art. 171 c.c arts. 14, inc. 11, e 29 do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória (fls. 184/187), no dia 21 de fevereiro de 2020, desde horário incerto, mas até por volta de 23h55, em diversas vias públicas, inclusive na Rodovia SP 320, altura do numeral 631, na cidade de Rubinéia, comarca de Santa Fé do Sul, CAIK DA SILVA SANTANA, conduziu o veículo VW/GOL 16V, ano 2000, cor preta, placas CVL3102, de Aparecida do Taboado/MS, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme sinais que foram atestados pelo laudo médico de fls. 3 e pela ficha de atendimento médico de fls. 34, na forma disciplinada pela Resolução Contran nº 432/2013.

Consta também que, naquele mesmo dia, já nas dependências do Auto Posto Paulistão, situado no endereço acima referido, por volta de 23h55, CAIK DA SILVA SANTANA e CÍCERO PINHEIRO MALHEIROS, previamente ajustados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram obter, para eles, vantagem ilícita no montante de R\$ 20,00, em prejuízo daquele estabelecimento comercial, ao induzir e manter em erro o frentista Robson Fernando Milanez, mediante artifício e ardil, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida na data de 08/01/2021 (fls. 218).

Os réus foram citados na data de 25/02/2021 (fls. 225 e 226) e apresentaram resposta à acusação as fls. 243/244.

A denúncia foi ratificada na data de 18/01/2022 (fls. 248/249).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e procedeu-se aos interrogatórios dos réus.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos boletins de ocorrências (fls. 4/10); pelo laudo médico do acusado (fls. 3); pelo auto exibição e apreensão (fls. 21); pela ficha de atendimento do acusado (fls. 34/35); pelos exames de copo de delito (fls. 198/201 e 215/216); pelos depoimentos em solo policial de André Ricardo da Silva (fls. 11), Antônio Carlos Olivo (fls. 12), Robson Fernando Milanez (fls. 13), CÍCERO PINHEIRO MALHEIROS (fl. 145); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria dos delitos é inconteste e recai sobre os acusados.

Em solo policial, a vítima Robson Fernando Milanez declarou que: "(...) sou frentista no Posto Paulistão e na data de hoje, alguns minutos antes da meia-noite, um Gol, de cor preta, com dois ocupantes chegou no posto, pediu para abastecer 20 reais de gasolina e observei que o motorista estava com a boca sangrando, todo ralado e o outro aparentava estar dormindo. Eu coloquei os 20 reais e perguntei a forma de pagamento, sendo que eles não responderam e passaram a 'enrolar', a cochichar e a mexer no interior das portas do veículo, como se fossem pegar algo. Eu achei que eles fossem pegar algo e sair do carro e por isso estranhei a situação e dei dois passos para trás. Em seguida, eles arrancaram com o carro, com a intenção de fugir e eu gritei por socorro, dizendo que eles estavam fugindo sem pagar. Observei que Antônio Carlos Olivo tentou abordá-los, sendo que ambos desceram e vi que um deitou no chão e outro foi para cima de Olivo. Ouvia Olivo mandando-o parar e ele não obedecia. Então ouvi o disparo. Olivo solicitou que chamasse a polícia e o resgate e, depois, me dirigi, junto com o policial militar, até esta Unidade Policial (...)".

Em juízo, a vítima declarou que os acusados chegaram no posto com veículo Gol Preto e pediram para abastecer vinte reais, ele reparou que eles estavam machucados. Após o abastecimento os dois ficaram cochichando dentro do veículo, nesse momento ele ficou com medo e em seguida eles arrancaram com o carro, quando o policial aposentado abordou o veículo.

Em solo policial, a testemunha Antônio Carlos Olivo declarou que: "(...) sou

cliente do Posto Paulistão de Rubinéia, sendo que duas a três vezes por semana abasteço no local e na data de hoje parei para abastecer e ao sair, encostei a camionete para acertar e observei um Gol, de cor preta, com duas pessoas no seu interior e o frentista Robson ao lado deles, aguardando eles pagarem. Fiquei aguardando-os saírem para pagar e achei estranho que o passageiro do carro, ficava mexendo no interior do carro, como se estivesse procurando alguma coisa. Dei sinal ao frentista que eu ia no banheiro e depois voltaria para pagar. Passei pelo Gol, passei pelas bombas, quando ouvi o frentista gritando em voz alta, que eles estavam fugindo. Imediatamente percebi que estava ocorrendo algo de errado, inclusive, notei que ele dirigia em forma de zig-zag e, por isso, quando eles passaram ao meu lado tentei abordá-los. Ele andou uns 15 ou 20 metros e o carro afogou. Então me aproximei, informei que era policial, saquei a arma e solicitei que eles descessem do carro. O motorista abriu a porta, desceu e vi que a fiação do carro estava solta, pedi para ele encostar no carro e ele deixou no chão. Pude observar no rosto dele que ele sangrava. Falei para a outra pessoa que estava no carro sair do veículo e ele demorou um pouco para sair, porque estava procurando algo no interior do veículo. Então ele saiu e passou pela frente do veículo e se aproximou do canto do carro. Eu falei para ele encostar no carro e ele disse que não iria encostar. Eu insistia que era policial e que ele tinha que encostar no carro, porém, ele passou a se aproximar, de forma agressiva, falando que ia me pegar e eu passei a recuar. Em certo momento, observei que não tinha mais jeito de sair dele, pois ele continuava avançando em minha direção e eu com a atenção voltada para ele e para o indivíduo que estava no chão e fazia menção de levantar, então tive que efetuar o disparo na perna dele. Informo que estava a aproximadamente um metro dele. Pedi para o pessoal do posto ligar para a viatura da polícia e também para o resgate e me dirigi a esta Unidade de Polícia Judiciária, onde apresentei os fatos, a arma de fogo e a documentação dela. Nesta Unidade, tomei conhecimento que minutos antes eles teriam tentado entrar em uma residência na cidade de Aparecida do Taboado - MS e que por isso o motorista estava com a boca sangrando. Também nesta Unidade tomei conhecimento que o veículo tinha bebida e um canivete. O indivíduo que atirei nele teria inclusive falado para os policiais militares que eu atirei nele em razão dele ter ido por cima de mim (...)"

Em juízo, a testemunha declarou que ele parou para abastecer sua caminhonete como de costume, quando ele viu um gol preto encostado. Avisou ao frentista que iria ao banheiro enquanto ocorria o abastecimento. Quando ele voltou do banheiro escutou o frentista gritando para que parassem o carro e em seguida ele saiu no encalço e perseguiu o veículo Gol em torno de 20 ou 30 metros. O veículo perseguido "afogou". Deu ordem de parada e que o motorista desceu e foi ao chão, porém o passageiro não obedeceu, demorou para descer, mexia em alguma coisa dentro do carro e quando desceu estava sangrando. Disse que visualizou dentro do carro que estava com o painel bagunçado e ele mandou o passageiro encostar no carro, porém ele não obedecia. Em seguida reiterou as ordens para que encostasse no carro e CÍCERO não obedecia, pelo contrário, o réu foi para cima do depoente de forma ameaçadora e somente parou quando a testemunha deu um tiro em sua perna. Por fim, afirmou que o acusado CAIK não ofereceu resistência, somente CÍCERO resistiu à abordagem. O acusado CAIK DA SILVA SANTANA, perante a autoridade policial, exerceu o direito constitucional do silêncio (fls. 15).

O réu, em juízo, declarou que, em relação à direção sob efeito do álcool, a acusação é verdadeira. No entanto, com relação à obtenção de vantagem indevida, a acusação não é verdadeira. Sobre os fatos contidos na denúncia, afirmou que chegaram no posto, abasteceram e o frentista foi até ele perguntando o valor a ser abastecido que eram vinte reais. Afirmou que CÍCERO era o proprietário do carro e que desceu do veículo para pagar o abastecimento. CÍCERO voltou ao carro e CAIK perguntou a ele se já havia sido pago o abastecimento e obteve resposta positiva. Saiu com o veículo e logo após sair das bombas apareceu o policial em outro veículo. O policial pediu para ele sair do carro e se deitar no chão, que assim o fez. Disse que pediu ao CÍCERO para deitar-se no chão em razão de que o policial estava armado. Perguntou ao policial a todo momento o que estava acontecendo e que foi agredido e perdeu dois dentes. Confirmou que estava conduzindo o veículo, mas

não saiu em alta velocidade e que não escutou o frentista gritando por socorro, em razão de estar com o vidro fechado. Por fim, afirmou que o pagamento do abastecimento seria realizado por CÍCERO.

O acusado CÍCERO PINHEIRO MALHEIROS, perante a autoridade policial, declarou que: "(...) é morador da cidade de Aparecida do Taboado/MS, sendo que na data dos fatos, estava na companhia de CAIK DA SILVA SANTANA, sendo que passaram a tomar cerveja, no entanto, sabe dizer que CAIK ingeriu pequena quantidade de bebida e o declarante uma quantidade maior, o qual lhe deixou embriagado. Em dado momento resolveu vir ao posto Paulistão de Rubineia para abastecer seu veículo, visto que naquele posto o preço do combustível era menor e compensava a vinda. Como havia bebido muito solicitou que CAIK viesse dirigindo o carro, pois considerava que ele estava sóbrio. Vieram até o posto tendo o declarante solicitado ao frentista para abastecer a quantidade equivalente a R\$20,00 de gasolina. Depois de abastecido foi procurar o dinheiro e não encontrou, mesmo com a certeza de que estava na posse da quantia informada. Procurou dentro do carro, mas não achou. Como estava sob o efeito do álcool acabou por conversar em tom alto com o frentista, mas em nenhum momento o ofendeu. No entanto, acredita que, o policial Antônio, ao perceber que conversavam alto, aproximou-se e identificou-se como policial, sacou a arma e pediu para que o declarante e CAIK deitassem no chão. Viu que CAIK deitou. O declarante assustou-se ao ver a arma, mas seu pensamento foi de ir até o carro e pegar o celular para ligar para a esposa, no intuito de verificar se o dinheiro havia ficado na casa e, então, pedir para ela trazer. Aduz que chegou a falar isso para o policial, mas devido ao barulho da aglomeração de pessoas, o policial não deve ter ouvido. Quando estava indo na direção do carro, ainda de frente para o policial, ouviu um tiro que pegou um pouco para cima do seu joelho. Caiu no chão e o policial chegou perto. Ainda deu tempo de novamente dizer que só ia pegar o celular e ligar para a esposa. O policial disse 'você só ia fazer isso mesmo?'. O declarante disse que sim, pois não é bandido. Depois disso desmaiou, voltando a consciência somente no dia seguinte já na Santa Casa de Santa Fé do Sul. Em relação ao canivete encontrado com CAIK, alega que não tinha conhecimento que ele portava tal objeto. Ficou internado na Santa Casa de Santa Fé do Sul por um dia e depois transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto por aproximadamente dezessete dias, passando por duas cirurgias (...)"

Em juízo, o réu CÍCERO afirmou que estava muito embriagado no momento e não se recorda de nada. Assevera que falou ao frentista que tinha esquecido do dinheiro e que ele não se lembra de alguns detalhes em razão de estar muito embriagado. Se lembra de ir até o carro buscar o dinheiro para pagar o abastecimento, quando levou um tiro do policial e acabou esquecendo do restante dos acontecimentos.

Essas são as provas.

Pois bem.

Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

Com relação ao crime do art. 306, §1º, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte de CAIK DA SILVA SANTANA.

De fato, ele confirmou em Juízo que estava dirigindo sob a influência de bebida alcoólica. Além disso, soma-se a este fato o laudo pericial de fls. 200/201, que constatou no réu sinais indicativos de embriaguez e de que estava sob efeito de álcool ou substância psicoativa.

Nesse contexto, há de se ressaltar que, nos termos do art. 306, §2º, do CTB "A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Assim, de rigor a condenação de CAIK como incurso nas penas do art. 306 do CTB.

Art. 171 do Código Penal

De início, o presente caso enseja a aplicação do instituto da emendatio libelli, nos termos do disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal, na medida em que a prova dos autos demonstrou com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta.

O crime de estelionato consuma-se, em sua forma fundamental, no momento e no lugar em que o agente obtém o proveito a que corresponde o prejuízo alheio. Conforme narrado na exordial acusatória, os acusados induziram em erro o frentista do posto de gasolina e, após abastecerem o veículo, saíram sem pagar. Como se nota, o iter criminis foi percorrido sem qualquer interrupção. A ação do ex-policial permitiu a prisão dos acusados, mas não evitou a consumação do crime.

Assim, tratou-se de crime consumado e não tentado.

Ressalto, por oportuno, que o acusado se defende dos fatos narrados, e não da tipificação efetuada na denúncia, de modo que, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, pode o juiz dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da denúncia.

Pois bem.

Não há dúvidas quanto à autoria de CAIK DA SILVA SANTANA e CÍCERO PINHEIRO MALHEIROS, uma vez que a prova oral produzida em juízo foi harmônica no sentido de que os dois acusados agiram com unidade de desígnios com a finalidade de obter ganho pecuniário em face do posto de combustível "Auto Posto Paulistão".

Ficou provado pela oitiva da vítima que CAIK e CÍCERO, ao abastecerem o veículo Gol de cor preta que estava sendo conduzido por CAIK, usaram de meio artificioso para não pagarem o valor do abastecimento.

No caso, os acusados foram até o veículo após o abastecimento, simularam estar mexendo em algum objeto dentro daquele Gol de cor preta enquanto cochichavam e, em seguida, saíram do posto de combustível em desabalada carreira, em notório intuito de concretizar o ganho fácil que se propunham a fazer.

Não contavam, porém, com a presença do policial aposentado, senhor Antônio Carlos Olivo, que conseguiu eficazmente conter os acusados em sua fuga do local dos fatos. Importa mencionar que, durante a abordagem do policial aposentado, CÍCERO fez ameaças contra ele e instigou CAIK para que este também resistisse àquela abordagem.

Ora, a versão apresentada pelo réu CAIK de que já estaria confirmado o pagamento do abastecimento do veículo por parte de CÍCERO não justifica sua tentativa de saída às pressas do local dos fatos. De outro lado, a versão apresentada por CÍCERO não é plausível, em razão de que apresentou resistência à abordagem do policial, tentou enfrentar o policial e negou-se a deitar-se ao chão. Caso fossem verdadeiras suas versões, CAIK teria respondido aos suplícios do senhor frentista quando gritava para que parassem o veículo e, se não houvesse nada de errado nas suas condutas, CÍCERO não teria razão para tentar enfrentar fisicamente o policial Antônio Carlos Olivo.

No presente caso, as circunstâncias efetivamente convergem em desfavor dos acusados, conforme harmonioso conjunto probatório coligido aos autos, tornando incontestes a responsabilidade deles pelos crimes descritos na denúncia, na modalidade consumada.

Não pode ser acolhido o argumento de que a embriaguez do acusado excluiria a culpabilidade. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, conforme preleciona a teoria da actio libera in causa. O agente é livre na causa antecedente, ainda que durante a prática do delito estivesse embriagado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência

ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). 2. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer a tese segundo a qual o estado de embriaguez do ora Agravante se amolda ao quanto previsto no art. 28, caput ou § 2.º, do Código Penal, de maneira a aplicar-lhe as benesses previstas nesses dispositivos legais, implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 3. Mantidas as penas fixadas pelas instâncias ordinárias, prejudicado está o pleito pelo estabelecimento do regime inicial aberto. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1551160 SP 2019/0226240-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Noutra vertente, para o acolhimento da inimputabilidade por embriaguez patológica, indispensável se faz a produção de prova pericial, ou ao menos a juntada de atestado médico, sendo que nem um nem outro ocorreu no presente caso. Para a comprovação da patologia, é insuficiente a prova testemunhal.

Não incide na hipótese o princípio da insignificância, pois não se pode estabelecer o requisito da inexpressividade da lesão jurídica. No caso em apreço, em que os acusados tentaram empreender fuga do local dos fatos e intimidaram a testemunha, o perigo potencial da conduta ao bem jurídico é bastante intenso e até mesmo de difícil mensuração. Portanto, a conduta é grave e digna da reprovabilidade penal. Assim, certifico também a presença da ilicitude e culpabilidade dos acusados ao praticar a conduta.

De toda sorte, os acusados fazem jus ao benefício do art. 171, §1º, do Código Penal:

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.

Art. 155, §2º, do Código Penal

(...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa

Deste modo, tratando-se de benefícios alternativos, verifico que a hipótese que melhor atende as finalidades geral e especial da pena é a substituição da reclusão pela detenção.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

CAIK DA SILVA SANTANA

DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

Código de Trânsito Brasileiro